

达的转让通知中载明的受让人履行债务后即可免责。因此第一个转让通知到达债务人后，债务人就受到相应债权转让的约束，应当向该通知所载明的受让人履行。后面的转让通知如果与先到达的转让通知全部或者部分冲突，则意味着要撤销或者部分撤销在先到达的转让通知，但是在先通知未经相应受让人同意不得撤销，故后到达的通知在与先到达的通知的冲突范围内，不可能发生撤销的法律效力。该规则简单明确，债务人不需要判断外部关系中谁是真正的权利人，亦不负有审核义务，对于债务人而言无疑是非常有利的。

三、应当有条件地承认受让人作为债权转让的通知主体

关于债权转让通知的适格主体问题。《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉合同编通则若干问题的解释》第四十八条第一款采用“债务人接到债权转让通知”的表述，有意作了模糊处理。那么受让人能否成为债权转让通知的主体呢？支持意见认为，对债务人发出通知，是债权转让对债务人发生法律效力必备条件，法律未限制仅由让与人作为通知主体，特别是在一些情况下，让与人可能无法对债务人发出通知，在受让人能够提供充足的证据证明债权转让的事实时，可以允许其对债务人作出通知。反对意见则认为，如果允许受让人发出通知，债务人就会承担过高审核义务，并会因此处于两难境地而遭受不利，不利于对债务人的保护。笔者认为从促进交易便捷开展及债务人保护双重角度看，应当有条件地允许受让人成为通知的主体。

编写人：重庆市第五中级人民法院 陈黎黎

以物抵债后可否就原债权主张权利

—— 王某诉信某民间借贷案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

吉林省吉林市船营区人民法院(2023)吉0204民初4756号民事判决书

2. 案由：民间借贷纠纷

3. 当事人

原告：王某

被告：信某

【基本案情】

信某向王某借款200000元，王某于2020年8月10日至2020年9月28日向信某指示的银行账户转款180280元，2020年9月3日向信某银行账户转款50000元。信某向王某出具落款日期为2020年9月3日的《借条》，载明：“今借到王某200000元人民币，贰拾万圆整，年利率一分利。”2020年10月5日，信某向王某支付40000元利息。之后，信某未偿还向王某借款，双方于2021年5月2日签订协议，载明：“甲方：信某，乙方：王某。由于甲方信某欠乙方王某人民币贰拾万元(20000元)，现将吉B×xx×× 某品牌车辆顶账给乙方，甲方负责将此车贷款还款直到全款为止，即日起，此车交接后的一切违章和事故由乙方承担，甲方将交接之前所有违章处理完毕。特此协议，即日生效”。协议签订后，信某将车辆交付给王某。

【案件焦点】

1. 借款本金及利息如何认定；2. 抵账协议是否应当继续履行。

【法院裁判要旨】

吉林省吉林市船营区人民法院经审理认为：合法的民间借贷受法律保护。信某向王某借款，王某向信某提供了借款，双方形成民间借贷合同关系，合法有效。王某主张借款本金为200000元，信某亦自认借款本金为200000元，法院对借款本金金额予以确认。关于利息，因信某答辩时自认于2020年10月5日向王某支付40000元利息，其出具的借条对利息进行了约定，故其认为没有约定利息的抗辩主张法院不予采信。信某出具借条落款时间为2020年9月3日，一个月期间信某支付40000元利息，超出双方约定及法律规定，信某主张抵付本金，法院予以采纳。因双方约定年利率1分利（10%），故至2020年10月5日，信某已偿还的利息应为 $20\text{万元} \times 10\% \div 365\text{天} \times 32\text{天} = 1753.42\text{元}$ ，偿还本金 $40000 - 1753.42 = 38246.58\text{元}$ ，剩余借款本金 $200000\text{元} - 38246.58\text{元} = 161753.42\text{元}$ 。王某以起诉的方式要求偿还借款，信某答辩称同意偿还，故法院支持信某向王某偿还借款本金161753.42元。信某与王某对如何偿还借款曾签订了协议，虽然协议约定信某用某品牌车辆抵顶借款，但鉴于信某已同意偿还借款，其车辆已交付王某使用两年多，信某主张使用车辆应冲抵利息的意见合理，法院予以采纳。综上，法院对王某合理的诉讼请求予以支持。

吉林省吉林市船营区人民法院判决如下：

一、被告信某于本判决生效之日起七日内偿还原告王某借款本金161753.42元；

二、驳回原告王某的其他诉讼请求。

宣判后，双方当事人均未上诉，一审判决生效。

【法官后语】

因为近年来民间资本融资高度活跃，使得民间借贷纠纷成为法院审理案件数量较多一类案由，民间借贷属于借款合同的范畴，但又具有偶发性、隐蔽性、

无序性等民间借贷特点。为此，在审理此类案件过程中不仅需要考虑《中华人民共和国民法典》合同编有关借款合同的规定以及《中华人民共和国民事诉讼法》《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》中关于证明责任的规定，在具体规则的适用上还应结合《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》进行审理认定。但鉴于案情的多样性，仍然有着相当一部分关于法律适用的问题需要解决，尤其是对于出现新型案例，法院的裁判结果会影响人们在从事民间借贷活动过程中的判断。

一、当事人意思自治应为法院审理民间借贷基本原则

《中华人民共和国民法典》第一百三十三条规定，民事法律行为是民事主体通过意思表示设立、变更、终止民事法律关系的行为。民事法律行为是民事主体实现意思自治的最重要手段和工具，自愿原则既是意思自治原则，也是民法的核心原则之一。当事人在民间借贷关系设立的过程中，需要通过意思表示体现自己的意图，并由此承担相应的法律后果，其中对于合同主体、借贷数额、还款期限、利率标准等事项均需要体现借贷双方的合意，此种合意的认定也是双方成立借贷关系的核心。实践中，当事人往往通过借条、欠条、收条等不同方式体现出借资金的意愿，在认定是否具有借贷合意以及借贷关系内容时原则上应当以上述书面材料反映的事项予以确定，但是考虑到民间借贷纠纷通常发生于熟人之间，或者因为资金需求

的紧迫性当事人之间并未签订书面的借款协议，此时在认定借贷行为是否属于当事人的意思表示，以及款项支付行为是否体现借贷合意的内容时，争议较大。例如，针对《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第十六条的理解适用，能否依据原告在民间借贷诉讼中提交的转账凭证推定当事人之间形成了借贷关系的合意、在被告抗辩并举证明所转款项是偿还其他借款或债务时法院应如何审核认定原被告证据并作出裁判等。对此，无论是借款合同还是其他借贷凭证，均是当事人为了体现要约和承诺达成一致的手段，此类案件审理过程中不仅需要对于已经存在的书面凭证进行审查，而且更应当关注出借人的借款能力、经济状况、款项来源、借贷关系产生的原因，包括当事人基于何种用款需求向出借人发出借款的

要约，借款人基于何种信任和利益回报承诺将款项出借等。只有当事人就合同的订立过程及书面借款凭证或者款项转账的原因及行为提供了充足证据并达到了高度盖然性之标准，才能依法确认借款行为属于当事人的真实意思表示，并在满足合同成立的其他条件下，按照合意内容依法确定各方的违约责任。此外，由于民间借贷关系建立时，借贷主体往往以逐利作为出借资金的重要考量因素，而鉴于《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》改变了过往“两线三区”而规定了“4倍LPR”的上限标准，出借人为了规避上述用款上限的规定，往往采取“砍头息”等方式提前收回用资成本，造成借款人实际能够使用的借款本金与书面借款合同的记载严重不符。此时，应当通过审查出借人于借款合同签订后实际向借款人支付款项的方式和数额，确定借款合同项下的本金，并按照借款合同的约定依法认定利息和相关费用，避免出借人额外获取不当利益。

具体到本案中，原告虽然提举的借条载明借款金额为200000元，但却未能提举相应的转账凭证，仅提举了60000元的银行转账凭证。若被告否认，原告在不能作出充分合理的解释说明及其他佐证的情况下，审理的难度加强。法院应当依照民间借贷司法解释的规定向双方进行充分、详尽的问询。本案被告答辩时承认了借款200000元，属于自认。那么法院在排除虚假诉讼的情况下应当遵循当事人的意思自治。双方形成的200000元借条并非一次性借款形成的，而是多次借款后累计出具的，视为当事人意思表示一致。关于利息，在超出双方约定利率的情况下应当予以抵扣本金。

二、以物抵债后可否就原债权主张权利

民间借贷纠纷案件，借款期限已至双方约定的日期，当事人对于如何偿还借款达成了新的合意，法院亦应当对其进行主动审查合法性。经审查后认为该新的合意系双方真实意思表示，且不违反相关法律法规规定，应认定为合法有效。当事人应当按照新达成的合同履行自己的义务。对于以何种方式偿还借款，在民间借贷案件中情况多种多样，如直接以金钱方式偿还借款、双方以原有债权抵销本次借款、借新还旧、债权债务转移、以物抵债、知识产权转移、股权

转让等。借款人直接以金钱这种最简单的方式偿还借款，那么双方借款关系消灭，极大地减少了可能产生的其他法律纠纷，也是生活实践中最常见的方式。如果借款人以其他方式来履行偿还借款的义务，则会产生新的法律关系，亦会发生新的法律纠纷。其中以物抵债方式最为常见。物，可以是房产等不动产，也可以是车辆等特殊动产，还可以是普通动产。对于借贷双方达成新的以物抵债，即对原有借款合同中约定的偿还借款方式进行根本性变更，借款双方的权利义务发生了根本性改变。这种变更可以是无条件的，也可以是附条件的。对于无条件的变更，法院应依据《中华人民共和国民法典》合同编相关法律规定对新形成的合同进行审查，合法成立的合同双方应当按照约定履行。新合同是否实际履行及能否继续履行是法院审理的重点。对于附条件的变更，应重点审查附条件此时是否形成。附条件若未形成，那么新合同是否成立是审理的重点；附条件曾形成但之后因一些原因消灭，那么新合同是否应当继续履行是审理的重点。新合同不能继续履行，或是没有履行的必要，那么为了充分保护出借人的合法债权，出借人仍可依据原来的借款关系主张权利。

例如，本案原告没有以以物抵账协议来法院告诉，而是以民间借贷关系向被告主张权利，即原告选择了对自己最为有利的请求权基础，那么法院应当充分遵循当事人权利处分的意思表示，围绕基础关系进行审理，但亦应听取被告的意见。该案被告已经依据双方新达成的以物抵债协议，将自己名下贷款购

买 的一辆轿车交予原告用以抵偿借款，轿车未还清的贷款由被告继承按揭偿还。 但本案被告并不主张借款已经因以物抵债履行了偿还借款的义务，而是表示同 意偿还借款，原因即为以物抵债协议是附有条件的，即被告负责将此车贷款还 款直到全款为止。庭审中原告述该车辆被他人开走，被告也承认贷款未按时偿 还，所以该附条件已消灭，原告不能占有使用该抵偿车辆，至此该协议客观上 履行不能。那么，原告以民间借贷为请求权基础而不是以交付车辆转移物权为 请求权基础来院告诉，是其保护自己权利最为有利的选择。法院不能主动以该协议已形成，借款偿还完毕驳回原告的诉讼请求。

编写人：吉林省吉林市船营区人民法院 赵越

债权人要求抵押人将抵押权登记在受托的第三人名下， 不影响债权人抵押权的实现

—— 笪某某诉曹某某民间借贷案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

安徽省天长市人民法院(2024)皖1181民初474号民事判决书

2. 案由：民间借贷纠纷

3. 当事人

原告：笪某某

被告：曹某某

【基本案情】

笪某某系某咨询公司的法定代表人，笪某某与曹某某经人介绍认识成为朋友，曹某某因资金周转需要向笪某某借款。2022年6月15日，笪某某通过某银行向曹某某汇款300000元。2022年8月26日，笪某某安排所在公司的员工高某某与曹某某签订了《抵押借款合同》，合同约定曹某某自愿将其所有的位于安徽省合肥市新站区某大道1×××号某商贸城K地块K×××幢办×××室抵押给高某某，作为借款300000元的担保，并在合肥市自然资源和规划局办理了不动产抵押。抵押证号为皖(2022)合肥市不动产证明第20××××号，其上载明的债务履行期限为2022年8月26日至2022年9月26日。

笪某某提出如下诉讼请求：(1)请求判令被告立即偿还原告借款300000元；(2)请求判令被告向原告支付利息50176元(以未还款300000元为基数，

按照利率1.28%/月，暂从2022年8月26日始计算至2023年9月21日止，此后计算至清偿之日止）；(3)请求判令原告享有高某某对被告位于安徽省合肥市新站区某大道1×××号某商贸城地块K×××幢办××室皖(2022)合肥市不动产证明第20×xxxx号抵押权；(4)判令被告承担本案全部诉讼费用。

【案件焦点】

债权人笪某某是否享有案涉抵押房产的抵押权，并要求实现抵押权。

【法院裁判要旨】

安徽省天长市人民法院经审理认为：对于借贷关系，原告要求被告偿还借款本金300000元，有原告提供的汇款凭证和微信聊天记录在卷佐证，对民间借贷关系，法院依法予以确认，原告有权要求被告履行还款义务。对于抵押权实现，根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉有关担保制度的解释》第四条规定：“有下列情形之一的，当事人将担保物登记在他人名下，债务人不履行到期债务或者发生当事人约定的实现担保物权的情形，债权人或者受托人主张就该财产优先受偿的，人民法院依法予以支持：（一）为债券持有人提供的担保物权登记在债券受托管理人名下；（二）为委托贷款人的担保物权登记在受托人名下；（三）担保人知道债权人与他人之间存在委托关系的其他情形。”原告将款项出借给被告后，因被告迟迟未还款，经协商被告同意用其所有的房屋为借款担保，并办理抵押登记。原告系某咨询公司的法定代表人，安排公司员工高某某与被告签订《抵押借款合同》，抵押权设立并生效。高某某本人出庭作证，证明是受原告的委托，与被告办理的《抵押借款合同》，其本人并未出借款项给被告，该合同项下的权利义务归于原告。故原告要求被告位于安徽省合肥市新站区某大道1×××号某商贸城K地块K×××幢办××室享有抵押权的诉讼请求，法院予以支持；《抵押借款合同》约定的借款利息为月利率1.28%，该利率约定未超过法律规定的上限，法院予以支持。

安徽省天长市人民法院作出如下判决：

一、被告曹某某于本判决生效之日起十日内给付原告笪某某借款300000元

及利息(以本金300000元为基数,从2022年8月26日起,按月利率1.28%计算至还清之日止);

二、原告笪某某对被告曹某某所有的位于安徽省合肥市新站区某大道1×××号某商贸城K地块Kxxxx幢办x××室房地产享有抵押权,可以协议折价或者拍卖、变卖抵押物所得予以优先受偿。

当事人未上诉,该案判决依法生效。

【法官后语】

实践中抵押登记制度的特殊规定和市场主体的特殊交易安排等因素,导致出现了实际债权人的担保物权无法设立的情况。为此,债权人常常通过委托第三人出借款项、委托第三人接受抵押权的形式完成交易,这对《中华人民共和国民法典》(以下简称《民法典》)立法原意和法学界通说的同一项债务的债权人与担保权人应当为同一主体这一原则提出了现实挑战,如何处理好债权与抵押权分离情形下抵押权的实现这一问题具有重要实践意义。

《民法典》第四百零七条规定,抵押权不得与债权分离而单独转让或者作为其他债权的担保。因此一般情况下,抵押权应当随着主债权一并转让,债权人应当是抵押物的抵押权人。原则上同一项债务的债权人与担保权人应当为同一主体,法条规定如此,学界通说也是如此。但在债券发行、委托贷款等商业实践及民间借贷、P2P网络借贷等具体情形中,抵押权人与债权人在身份上会出现分离,无论是在理论界,还是在司法实务中,就此情况下抵押权能否设立有着较大争议。为统一裁判尺度,《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉有关担保制度的解释》第四条规定:“有下列情形之一,当事人将担保物登记在他人名下,债务人不履行到期债务或者发生当事人约定的实现担保物权的情形,债权人或者受托人主张就该财产优先受偿的,人民法院依法予以支持……(二)为委托贷款人的担保特权登记在受托人名下……”该条采取“列举+概括”式,列举了两种最为典型、常见的适用情形,然后用兜底条款进行概括,目的在于避免为流通式甚至证券化抵押权的广泛运用开启方便之门。该规定实际上确认了因债权人与他人之间存在委托关系,导致登记的担保物权

人与实际的担保物权人不一致时，债权人有权就抵押财产行使抵押权，原则上承认了抵押权人与债权人分离情形下抵押权的设定效力。

立法对该特殊情形的确认，基于以下几点理由：(1)抵押权代持行为不违反物权法定原则。抵押合同中，如果未办理抵押登记，债权人也只能基于抵押合同主张相应的权利，不能请求确认享有抵押权。但委托合同是委托人和受托人约定，由受托人处理委托人事务的合同，本身不以导致物权变动为目的，因而不是物权变动的原因，当然不适用物权变动规则。换言之，在受托人基于委托人的授权对外从事法律行为，并且因之导致物权变动的情况下，就委托人与受托人之间的关系而言，本质上是如何确定权利归属即该权利归谁所有的问题，而非物权变动的问题。(2)登记并非确认抵押权归属的唯一形式。不动产抵押权登记生效与动产抵押权登记对抗，仅是指物上负担的生效与对抗，并不排斥当事人间就权利主体通过意思表示作出另外安排。《民法典》第二百三十四条规定，因物权的归属、内容发生争议的，利害关系人可以请求确认权利。因此，若抵押权代持的意思表示足以对抗登记内容的，可依据当事人之间的意思表示确认真实权利。出借资金的债权人是真实的抵押权人，登记的抵押权人实则是其代理人，代理人以自己的名义签订抵押合同、办理抵押登记，但法律后果全部归于被代理人，故抵押权人享有抵押权。(3)抵押权与债权是形式分离

而非 实质分离。因登记制度存在特殊规定等原因，虽然真实抵押权人与名义抵押权人 不一致，但只是形式上的不一致，实质上仍为同一，并不产生抵押权与债权 实质分离的结果，真实抵押权人作为债权人享有抵押权，符合《民法典》第三百九十四条关于抵押权的一般规定，亦符合《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉有关担保制度的解释》第四条的规定。(4)抵押人事先知情 不会对交易第三人不利。抵押权作为从权利，自身不具有与主债权分离交易的可能性，因此抵押人事先知情，将抵押权登记在其他主体名下，只是真实抵押 权人所作的一种交易安排，并不会对交易第三人产生实质上的不利影响。考虑到实践中之所以出现名实不一的情形，往往是名义权利人与实际权利人之间存在委托关系，且第三人对此知情的情形，故兜底条款将其限定在担保人知道债

权人与他人之间存在委托关系的其他情形。在此双重限定下，一般不存在滥用权利或者走向流通性甚至证券化抵押权的可能，也化解了学界的担忧。

从《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉有关担保制度的解释》第四条规定中，我们可以总结得出债权人欲实现抵押权需要满足两个条件：（1）债权人即委托人与受托人之间存在明确的委托关系；（2）抵押人明确知道该委托关系的存在。在实践中，首先，当事人应当尽到审慎义务，债权人委托受托人时应当尽量签订书面委托合同，如若没有，应当保留好通话录音或短信、微信聊天记录等，以清楚证明委托关系的成立；其次，债权人应当及时告知抵押人该委托关系，债权人、第三人和抵押人之间应该沟通到位，由债权人指示第三人按照要求与抵押人办理抵押手续，做到三者之间的法律关系明确，如此一来，才能不影响债权人对抵押权的行使。

值得注意的是，设置抵押权与债权相分离的行为不损害善意第三人的利益。首先，此案例中代理形式符合债权人无法自己办理抵押登记的现实需要，若不存在欺诈、侵犯第三人或者社会公共利益等情况，且未违反法律法规的效力性强制性规定时，从尊重公民意思自治、维护债权人利益的角度综合分析，应认定为有效。其次，从现行法律规定看，外观主义是为保护交易安全设置的例外规定，一般适用于因合理信赖权利外观或意思表示外观的交易行为。根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉物权编的解释（一）》第二条，实际权利人与名义权利人的关系，应注重财产的实质归属，而不能单纯取决于公示外观。

在债权与抵押权分离的特殊情形下，担保物权归属于债权人的合理依据在于，担保物权的归属问题是确定权利归属即该权利归谁所有的问题，并非要求物权上的变动，基于委托人与受托人之间明确的委托关系，在尊重当事人各方真实意思表示、依法办理相关登记手续、不存在导致合同无效的情形下，债权人作为真实抵押权人，理所应当获得抵押权。此时，不论是基于权利义务相一致原则，还是基于受托人应当将取得的财产转交委托人的规则，抑或基于诚实信用原则，都应当认定委托人是实际权利人。

从抵押权人与债权人产生分离的原因来看，既有法律制度的约束，也有实践操作上的不当，故有必要承认债权人可突破登记主张抵押权。而且，这也并未因强调对债权人的保护，而损害受现行立法保护的第三人合法权益。学理上基于物权变动的“公示原则”和“公信原则”，在抵押权人与债权人分离的情形中，抵押登记确实是通过名义上的抵押权人代债权人完成，但只要并未影响应受法律正常保护的交易安全，就应当承认这种抵押登记的效力。换言之，只要当事人之间的意思自治并不涉及其他人的利益或者说对于他人的利益给予了足够的保护，法律上也就不应当加以干涉。

在债权与抵押权分离的特殊情形下，需要看清实际权利人与名义权利人之间的关系，从财产的实质归属出发去认定担保物权的权利归属，而不能单纯取决于公示外观，如此才能应对实践难题，有效维护好市场真实交易的合法秩序。

编写人：安徽省天长市人民法院 单斌 杨雪峰

债务人未积极履行以物抵债协议的，
债权人有权请求债务人履行旧债务

—— 贺某等诉某投资公司、汤某某民间借贷案

1. 判决书字号

浙江省绍兴市中级人民法院(2023)浙06民终639号民事判决书

2. 案由：民间借贷纠纷

3. 当事人

原告(被上诉人): 贺某、张某某、贺某某

被告(上诉人):某投资公司

被告:汤某某

【基本案情】

2016年10月26日,三原告(甲方)与汤某某(乙方)、某投资公司(丙方)签订《股权转让协议》一份,协议明确某投资公司现有主要资产为某项目土地使用权拍卖成交权、售楼部资产、银行存款320多万元,其中某项目土地使用权拍卖成交权现存在权利瑕疵,约定:丙方向甲方的借款金额5777万元,核对无误后由丙方出具手续确认,该款项由丙方在2017年1月底前付清本金和利息(按年利率20%计算)……2016年11月29日,三原告(甲方)与汤某某(乙方)、某投资公司(丙方)签订《补充协议(二)》一份,约定:(1)原《补充协议》第二条约定:伍仟捌佰万元股权转让价款的合理财务成本由双方另行商定。现甲、乙双方根据该约定以及甲方投入到某投资公司的融资成本,双方一致商定由乙方自2016年1月1日起至实际付清日止按年利率20%计算支付甲方利息,归还顺序为先利息后本金。(2)原《股权转让协议》第三条约定丙方向甲方的借款伍仟柒佰柒拾柒万元,现各方已核对无误,丙方确认已向甲方借款伍仟柒佰柒拾柒万元,对此丙方不再另行向甲方出具借条。对该借款中的伍仟万元部分按年利率20%计息,计息时间自2016年5月19日开始;其余柒佰柒拾柒万元不计息。归还借款本息的顺序为依法先利息后本金。2018年11月1日,三原告(甲方)与汤某某(乙方)、某投资公司(丙方)签订《协议书》一份,约定:(1)乙方、丙方共同确认:截至本协议签订之日,尚欠甲方的债务总额为11577万元及利息(借款5000万元自2016年5月19日起按年利率20%计算)。(2)乙方、丙方承诺在2018年11月30日前支付2000万元,余款自12月份起分月逐步付清。如任一期逾期支付,甲方可立即要求乙方、丙方履行全部债务。(3)丙方为确保上述债务的履行,同意以其开发的12套房屋作为抵押物,为上述债务提供抵押担保。抵押方式为甲方指定人员与丙方签订商品房买卖合同(具体内容详见双方签订的商品房买卖合同),并办理备案手续,丙方出具相应金额的收据或者发票给甲方。丙方应在本协议签订后七个工

作日内办理相关合同签订、备案等手续。(4)如乙方或丙方还清上述债务,甲方将抵押手续(包括合同、发票、收据等)退回丙方。如到期不能清偿全部债务,丙方同意以上述抵押物抵顶债务,多退少补。甲方有权选择要求丙方履行上述商品房买卖合同抵顶债务……

之后,三原告(甲方)与汤某某(乙方)、某投资公司(丙方)签订《补充协议》一份,明确乙方、丙方无法根据《协议书》规定在2018年11月30日前支付2000万元,经三方协商一致,达成以下补充条款:(1)甲方、乙方、丙方一致确认,本协议签订时,乙方、丙方对甲方所负的全部债务期限均届满;(2)丙方同意以其开发的10套房屋作价人民币5000万元抵充上述债务,丙方应在本补充协议签订后七天内与甲方指定人员(某厨具公司)签订商品房买卖合同(预售),并办理网上备案等相关手续……

【案件焦点】

以物抵债协议是否具有形成新债并消灭旧债的效力。

【法院裁判要旨】

浙江省嵊州市人民法院经审理认为:关于本案是否存在“旧债消灭”,原告主张金额是否应当扣除5000万元款项。以物抵债,系债务清偿的方式之一,是当事人之间对于如何清偿债务作出的安排,故对以物抵债协议的效力、履行等问题的认定,应以尊重当事人的意思自治为基本原则。一般而言,除当事人明确约定外,当事人于债务清偿期届满后签订的以物抵债协议,并不以债权人现实地受领抵债物,或取得抵债物所有权、使用权等财产权利,为成立或生效要件。只要双方当事人的意思表示真实、合同内容不违反法律、行政法规的强制性规定,合同即为有效。本案中,当事人之间《补充协议》(签订日期无注明)签订的《房屋抵顶工程款协议书》,是双方当事人的真实意思表示,不存在违反法律、行政法规规定的情形,故该协议书有效。

当事人于债务清偿期届满后达成的以物抵债协议,可能构成债的更改,即成立新债务,同时消灭旧债务;亦可能属于新债清偿,即成立新债务,与旧债

务并存。基于保护债权的理念，债的更改一般需有当事人明确消灭旧债的合意，否则，当事人于债务清偿期届满后达成的以物抵债协议，性质一般应为新债清偿。换言之，债务清偿期届满后，债权人与债务人所签订的以物抵债协议，如未约定消灭原有的金钱给付债务，应认定系双方当事人另行增加一种清偿债务的履行方式，而非原金钱给付债务的消灭。本案中，双方当事人签订了《补充协议》，但并未约定因此而消灭相应金额的借款债务，故该协议在性质上应属于新债清偿协议。

所谓清偿，是指依照债之本旨实现债务内容的给付行为，其本意在于按约履行。若债务人未实际履行以物抵债协议，则债权人与债务人之间的旧债务并未消灭。也就是说，在新债清偿时，旧债务于新债务履行之前不消灭，旧债务和新债务处于衔接并存的状态；在新债务合法有效并得以履行完毕后，因完成了债务清偿义务，旧债务才归于消灭。就本案而言，《中华人民共和国物权法》第九条第一款规定：“不动产物权的设立、变更、转让和消灭，经依法登记，发生法律效力；未经登记，不发生法律效力，但法律另有规定的除外。”据此，除法律另有规定外，房屋所有权的转移，于依法办理房屋所有权转移登记之日发生法律效力。而本案中，《补充协议》签订至今，案涉房屋至今未办理网签、预告登记等手续，故原告对案涉房屋并未享有物权或者物权期待权，在案涉房屋并未预告登记在某厨具公司名下或者由其使用的情形下，某投资公司并未履行《补充协议》约定的义务，故原先的5000万元债权并未消灭。

最后，当事人应当遵循诚实信用原则，按照约定全面履行自己的义务，这是合同履行所应遵循的基本原则，也是人民法院处理合同纠纷时所应秉承的基本理念。据此，债务人于债务已届清偿期时，应依约按时足额清偿债务。在债权人与债务人达成以物抵债协议、新债务与旧债务并存时，确定债权人应通过主张新债务抑或旧债务履行以实现债权，亦应以此作为出发点和立足点。若新债务届期不履行，致使以物抵债协议目的不能实现的，债权人有权请求债务人履行旧债务；而且，该请求权的行使，并不以以物抵债协议无效、被撤销或者被解除为前提。本案中，涉案债务在2018年11月已经到期，但某投资公

司却未能依约履行该义务。相反，就其所欠的部分借款，某投资公司试图通过以部分房屋抵充的方式加以履行，遂与原告签订了《补充协议》。对此，某投资公司亦应按照该协议书的约定积极履行相应义务。原告提起本案诉讼要求被告某投资公司返还借款后，被告某投资公司在前几次庭审中从未提起要求抵债的请求，仅在最后一次庭审中提起。从涉案《补充协议》的约定看，原告签订该协议，意为取得案涉房屋的物权期待权，从而实现其相应的借款债权。自协议签订之日至今已四年多，案涉房屋仍未办理网签、预告登记等手续，某投资公司亦无证据证明其已经积极履行催告、提示等义务。综上所述，某投资公司未积极履行《补充协议》约定义务的行为有违诚实信用原则，签订《补充协议》的目的至今未予实现。在此情形下，原告提起本案诉讼，请求某投资公司返还借款，符合本案实际以及法律规定，应予支持。

浙江省嵊州市人民法院判决如下：

一、某投资公司返还贺某、张某某、贺某某借款本金5777万元及相应的利息（以5000万元为基数自2016年7月31日起至2020年8月19日止按年利率20%计算，自2020年8月20日起至付清日止按同期全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率的四倍计算，扣除已支付的利息200万元），款项限于本判决发生法律效力之日起三十日内付清；

二、汤某某对上述款项承担连带责任。汤某某承担保证责任后，有权向某投资公司追偿；

三、驳回贺某、张某某、贺某某的其余诉讼请求。

某投资公司不服原审判决，提起上诉。

浙江省绍兴市中级人民法院经审理认为：上诉人主张三方已通过签订以物抵债的《补充协议》方式形成了新债并消灭了旧债，故三被上诉人已无权再向上诉人主张履行案涉旧债。对此法院认为，形成新债并消灭旧债需要有各方当事人明确的一致意思表示，特别是对债权人而言，需要其以明示的方式来放弃旧债权债务，否则会损害债务人的合法权益。本案中，三被上诉人显然并没有明确表示放弃案涉旧债，而上诉人不但未履行以物抵债的《补充协议》，反而还

曾一度对该协议的效力提出异议，故应认为上诉人提出的三被上诉人已无权再向其主张旧债的理由不能成立，上诉人应当向三被上诉人承担案涉借款的还本付息责任。同时，原审被告亦应当对此承担保证责任。浙江省绍兴市中级人民法院判决如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

以物抵债作为债务清偿的方式之一，在现实经济生活中大量存在。然而，不管是已失效的《中华人民共和国合同法》还是现在的《中华人民共和国民法典》，均未对以物抵债作出明确规定。理论上一般认为，“以物抵债，在法律行为的层面，是指当事人双方达成以他种给付替代原定给付的协议”。2023年12月5日施行的《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉合同编通则若干问题的解释》（以下简称《合同编通则解释》）按达成协议的时间在债务履行期限届满后和届满前，在第二十七条、第二十八条对以物抵债协议的效力予以规制。《合同编通则解释》第二十七条在总结司法实践经验的基础上，围绕对债权人的保护，将以物抵债协议规定为诺成合同，确立了清偿型以物抵债协议生效后新旧债并存的规则。

一、以物抵债协议的效力认定

（一）协议效力

一般而言，除当事人明确约定外，当事人于债务履行期限届满后签订的以物抵债协议，并不以债权人现实地受领抵债物，或取得的债务所有权、使用权等财产权利为成立或生效要件。只要当事人之间的意思表示真实，合同内容不违反法律、行政

法规的强制性规定，合同即为有效，合同自当事人表示一致时生效。

（二）法律效果

以物抵债协议成立生效后到实际履行完毕前，会出现新旧债并存的现象，即以物抵债协议会产生以下两种法律效果：一是债的更改，即成立新债务，同时消灭旧债务。二是新债清偿，即成立新债务，与旧债务并存。

二、新旧债并存下的选择权

(一) 性质认定

基于保护债权的理念，债的更改一般需有当事人明确消灭旧债的合意，否则，当事人于债务清偿期届满后达成的以物抵债协议，性质一般应为新债清偿。换言之，债务清偿期届满后，债权人与债务人或第三人所签订的以物抵债协议，如未约定消灭原有的金钱给付债务，应认定系双方当事人另行增加一种清偿债务的履行方式，而非原金钱给付债务的消灭。只有在新债履行完毕之后，旧债才消灭。

(二) 选择权行使

在当事人没有约定变更的情况下，现行司法解释推定以物抵债协议并不存在“债的更改”的意思，而仅仅是约定了新的债务履行方式，此时新旧债得以并存。这就产生履行新债还是旧债的选择问题。《中华人民共和国民法典》第五百一十五条规定了选择之债中选择权的归属与转移，该条文规定，在选择之一债中，债务人享有选择权。因此，在两种债务出现并存的情况时，首先赋予债务人选择履行新债还是旧债的选择权。即以物抵债协议达成后，选择权归债务人，债务人坚持履行新债，债权人不能反悔或者迟延接受履行，债权人反悔的，人民法院不予支持；债权人迟延接受履行的，则应承担违约责任。债务人或者第三人在约定期限届满前未履行以物抵债协议，经催告后在合理期限内仍未履行的，选择权转移至对方(债权人)。即只要以物抵债协议履行期限届满，经催告之后仍不履行，则债权人可选择请求债务人履行旧债，也可请求债务人履行新债，人民法院应尊重债权人的选择。而债权人一经选择，对债务人而言，就负有履行该选定债务的义务。对于第三人所有物抵债的，亦同理。

三、类案的审查要点和审理思路

(一) 运用“穿透式”审理思路

实践中存在的以物抵债协议，其协议名称与表现形式多种多样，有的直接在合同中约定以特定物冲抵原债务，有的则以另行签订买卖合同、股权转让协议等较为隐蔽的方式出现。且当事人约定的以物抵债协议究竟产生何种效力，

也需要根据当事人的约定来具体判断。这就需要法官在审理该类案件中采取穿透式司法审判思路探究协议背后当事人的真实意思，避免隐藏的意思表示，以有效区分不同情形下适用的相关规则。比如，在本案中，三方间签订了《补充协议》，内容中明确了协议签订时全部债务期限均届满并以开发的房屋抵冲债务。根据协议的约定，各方当事人系在债权届满后再行确定以房屋(预售)抵充债务，法律性质上应当认定为“以物抵债”，而非“让与担保后享有优先受偿权”。

(二) 采取四要点审查方法

当事人在履行合同时应遵循诚实信用原则，法院在处理合同履行纠纷时也秉承该基本理念。因此，在债权人与债务人达成以物抵债协议、新债务与旧债务并存时，确定债权人应通过主张新债务抑或旧债务履行以实现债权，亦应以此作为出发点和立足点。在案件审查中，可采取四要点审查方法。一是审查当事人是否有以新债代替旧债的合意。即审查协议中是否有以标的或性质不同于原债的新债取代原债，并因此导致原债消灭的明确合意，如果当事人间没有明确约定的，则只能认定为双方对履行方式的“新约定”，不能认定以物抵债协议已彻底替代原债权债务关系。二是审查协议达成时间是在履行期限届满前还是履行期限届满后。根据协议达成时间在期前还是期后，分别适用《合同编通则解释》第二十七条、第二十八条规定。但是，若协议虽形成于履行期限届满之前，但是债务人明确放弃了期限利益的，则亦属于履行期届满后达成的以物抵债协议。三是审查选择权行使主体。根据上文对选择权的规定，确定选择权由债务人享有还是债权人享有。通过选择权的行使将选择之债变成简单之债。四是审查抵债物权是否存在权利瑕疵。在以物抵债协议的履行中抵债物有瑕疵的情况下，相当于新债没有履行完，债权人可以要求解除以物抵债协议并履行旧债。但是，如果当事人违反权利瑕疵担保义务的情节较为轻微，债权人不能据此请求解除以物抵债协议，则债权人在选择以物抵债后，只能依据新债的合同请求抵债人承担违约责任。

以本案为例，当事人在以物抵债协议中并未有消灭旧债的明确约定，应认

定为新旧债并存。某投资公司并未能按照协议约定积极履行以物抵债协议的相应义务，自协议签订之日起至案件审理时已长达四年多，对案涉房屋仍未办理网签、预告登记等手续，某投资公司亦无证据证明其已经积极履行催告、提示等义务，以物抵债协议至今未能实现，原告作为债权人已给予债务人某投资公司合理履行期限，故原告享有请求履行原债务或者以物抵债协议的选择权。原告提起诉讼要求某投资公司履行旧债务，法院应予支持。因本案裁判时《合同编通则解释》尚未颁布，但是裁判思路与《合同编通则解释》的规定相一致，对类案仍具有借鉴意义。

编写人：浙江省嵊州市人民法院 汪丽娜 相泽波

五、利息与违约金认定

45

关于民间借贷预扣高额“砍头息”的认定和处理

—— 许某某诉陈某某、刘某民间借贷案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

广东省河源市中级人民法院(2023)粤16民终1754号民事判决书

2. 案由：民间借贷纠纷

3. 当事人

原告(被上诉人): 许某某

被告(上诉人): 陈某某、刘某

【基本案情】

2020年11月11日,陈某某、刘某因某信息公司名下投资于某科技公司股权的收购,向许某某借款6600万元。双方签订《借款合同》,约定借款期限为七个月(自2020年11月13日起至2021年6月12日止),月利率1.25%,每期利息82.5万元,于每月13号前支付完毕。在借款到期日前(含当日),须一次性偿还本金。

2020年11月12日,陈某某、刘某向案外人黄某某支付577.5万元。

2020年11月13日，许某某将借款转账至陈某某名下银行账户。

2020年12月11日至2021年5月13日，陈某某、刘某每月向许某某支付82.5万元。

2021年6月11日，因未能归还借款，陈某某、刘某向许某某出具《承诺书》，承诺将继续支付利息并接受利率的提高，与借款相关的各类抵押、质押、担保等持续有效。2021年7月8日，许某某与陈某某、刘某签订《借款展期协议书》，确认借款人尚欠借款本金金额为6600万元，借款期限展期至2022年1月10日，延展期内月利率为2.5%。为保障许某某债权得到实现，陈某某、刘某提供了位于深圳市的6套房产抵押及股票股权质押的担保措施，双方均签订了《抵押合同》《证券质押合同》，并办理了相关他项权登记手续。

2021年6月15日至2021年11月13日，陈某某、刘某向许某某每月支付165万元。

2021年12月13日至2022年5月18日期间，陈某某、刘某不再按月支付利息，而是不定期向许某某支付共965万元。借款延展期限已过，陈某某、刘某经催告仍未偿还全部本金。

2022年5月19日，许某某诉请法院判令陈某某、刘某偿还借款本金56144025.91元(关于该本金的计算方式，许某某未能明确给出)，并按照合同签订时一年期LPR(3.85%)的四倍(年利率15.4%，月利率1.283%)计算利息至还清款项之日止；判令许某某在案涉债务范围内对陈某某、刘某提供的抵押、质押物经处置后所得价款优先受偿。

截至原告起诉时，陈某某、刘某总共支付2450万元。

一审庭审中，许某某认可陈某某、刘某已付款2450万元；陈某某、刘某则认为，其于2020年11月12日向案外人黄某某支付的577.5万元系案涉借款预先扣除的利息，应在借款本金中扣除，并主张实际已付款3027.5万元(2450万元+577.5万元)。

二审时，案外人黄某某称，陈某某于2020年11月12日转到黄某某账户的577.5万元属于介绍费。黄某某称，其与许某某是朋友关系，其曾是许某某父

亲公司的员工，其通过朋友李某某知晓陈某某需要一笔资金周转，并介绍陈某某与许某某相识借款。李某某、黄某某、陈某某达成协议：由陈某某按照每个月本金的1.25%的标准，向黄某某支付七个月的介绍费。。

【案件焦点】

陈某某、刘某向黄某某支付的577.5万元是否属于“砍头息”。

【法院裁判要旨】

广东省河源市东源县人民法院经审理认为：许某某与陈某某、刘某签订的《借款合同》《借款展期协议书》《抵押合同》《证券质押合同》系合法有效的合同。关于借款本金及利息，首先，陈某某、刘某于2020年11月12日向案外人黄某某支付577.5万元，转账凭证并未备注该款的用途，陈某某、刘某亦未提交证据证实许某某要求其将该款转账给黄某某，许某某也不予认可，且该款的转账时间与借款时间有出入，不符合一般借贷实践；再从陈某某、刘某的付款记录来看，在时间、金额上均具有一定的规律性，符合定期支付固定金额的借款利息的特征，且与许某某主张2021年6月前按月利率1.25%计息，之后按月利率2.5%计息的事实相吻合。如果577.5万元系预先扣除这七个月合同外月利率1.25%的利息，那么陈某某、刘某在2021年6月仍向许某某付息165万元，显然与事实不符，两者相互矛盾。因此，陈某某、刘某主张577.5万元应在借款本金中扣除，缺乏事实及法律依据，不予支持。根据《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第二十八条的规定，借贷双方约定的利率不得超过合同成立时一年期贷款市场报价利率的四倍，所以本案许某某最高可得利息应按照合同签订时的一年期LPR(3.85%)的四倍(年利率15.4%，月利率1.283%)计付。陈某某、刘某支付超出应付利息部分，予以抵扣借款本金。东源县法院经核算，两被告尚欠借款本金56742040元 $[6600\text{万元}-(2450\text{万元}-6600\text{万元}\times 18\text{个月}\times 1.283\%)]$ 。原告许某某诉请的借款本金56144025.91元未超出法院核算金额，故予以支持。陈某某、刘某提供抵押的房产及质押股票已办理他项权登记，许某某诉请在涉案债务范围内对抵押、质

押物经处置后所得价款优先受偿，予以支持。

广东省河源市东源县人民法院判决如下：

一、陈某某、刘某于判决生效之日起十日内偿还许某某借款本金56144025.91元及利息，利息以56144025.91元为基数自2022年5月19日起按照月利率1.283%计算至还清款项之日止；

二、如陈某某、刘某未履行上述第一项判决，则许某某有权对抵押的房产、质押的股票折价或者拍卖、变卖所得的款项优先受偿；

三、驳回许某某的其他诉讼请求。

陈某某、刘某不服一审判决，提出上诉。广东省河源市中级人民法院经审理认为：一审认定许某某与陈某某、刘某签订的《借款合同》《借款展期协议书》等合同是合法有效的，符合法律规定，并无不当。关于陈某某、刘某向黄某某支付的577.5万元是否属于预先在本金中扣除的利息，应否在本金中扣减。陈某某于2020年11月12日向黄某某支付577.5万元，许某某于2020年11月13日向陈某某支付借款6600万元，且借款6600万元按照月利率1.25%计算七个月的利息为577.5万元。陈某某向案外人黄某某支付的577.5万元，黄某某是出借人许某某父亲公司的员工，黄某某认为该577.5万元是借款“介绍费”，但未提供任何证据予以佐证，且明显数额巨大并与常理不符，不予采纳。综合借款的转账时间、借款形成经过、利息约定和付款金额等，认定577.5万元属于案涉借款预先扣除的利息。故本案实际出借本金应为6022.5万元(6600万元-577.5万元)。

根据《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第二十八条的规定，2020年11月13日至2022年5月18日期间的借款利息，最高可以按照合同签订时的一年期LPR(3.85%)的四倍(年利率15.4%，月利率1.283%)计付，在此期间陈某某、刘某支付超出应付利息部分，予以抵扣借款本金。经核算，陈某某、刘某仍应向许某某偿还借款本金49635738.94元 $[6022.5\text{万元}-(2450\text{万元}-18\text{个月}\times 6022.5\text{万元}\times 1.283\%)]$ 。该未付本金的逾期利息，自2022年5月19日起以49635738.94元为基数，按合同签订时的

LPR 一年期的四倍(月利率1.283%)计付,计算至还清本金之日止。

广东省河源市中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第二项之规定,作出如下判决:

一、撤销广东省东源县人民法院(2022)粤1625民初1575号民事判决;

二、陈某某、刘某应于判决生效之日起十日内偿还许某某借款本金49635738.94元及利息(利息以49635738.94元为基数自2022年5月19日起,按照月利率1.283%计算至还清本金之日止);

三、如陈某某、刘某未履行上述第二项判决,则许某某有权对抵押的房产、质押的股票折价或者拍卖、变卖所得的款项优先受偿;

四、驳回许某某的其他诉讼请求。

【法官后语】

民间借贷司法实践中,出借双方借贷金额巨大、现金交付情况突出、提前扣除利息频发等问题,是纠纷的主要成因。款项交付的证据认定、举证责任分配、利息计算及保护范围等问题是长期困扰审判实践的难题。当事人为规避法律规定,手段日益多样化、隐蔽化,如当事人提前扣除利息的做法,使得借款本金数额的认定成为事实认定的难点。

一、“砍头息”的含义

一般来说,借款利息是在借款期限届满时或者合同履行期间按照约定分批偿付给贷款人。就利息性质而言,利息是按约定利率计算的孳息,是借款人支配和使用借款本金所承担的成本,是借款人使用该借款本金所创造的经济效益一部分利润转移给出借人。如果事先从借款本金中扣除利息,俗称“砍头息”。“砍头息”并非法律术语,而是对在借贷关系中出借人为确保其利息的收回,在支付借款时将部分本金作为利息预先在总金额中予以扣除行为的一种俗称。

二、“砍头息”的形式和认定

实践中,“砍头息”的表现形式多种多样,主要存在以下三种方式:一是出借人实际扣减利息后以现金形式向借款人支付借款本金,借款人向出借人出具全额书面借款凭证;二是出借人通过转账形式向借款人支付借款本金,借款

人则以现金方式向出借人支付约定的扣除利息，借款人向出借人出具全额书面借款凭证；三是出借人以转账方式向借款人支付全额借款本金，借款人随即将利息支付给出借人，借款人向出借人出具全额书面借款凭证。另，实践中广泛存在出借人放贷计息利率超出法律规定的保护范围，为使收取利息利率合法化，提前预扣部分利息，但不以“利息”名义收取费用，而是以“咨询费”“顾问费”“服务费”“中介费”等名义收取相关费用。贷款发放后，借款人按约定合法的利率付息。

对于典型的“砍头息”，即在出借款项时直接扣除利息后再交付本金，其表现形式直接，依照相关法律规定予以认定即可。对于非典型的“砍头息”（主要是费用型“砍头息”）的审查，普遍适用的标准就是债权人或其关联方收取相应款项是否具有“合理性”，即是否可合理相信相关款项和费用支付确实具有“利息”的用途，以及是否基于合理目的或合理原因收取款项。同时，要着重审查以下四个方面：一是借款人对相应部分的本金是否失去支配权。“砍头息”的核心是出借人未能实际使用、支配用于支付利息或其他款项的本金，且需支出额外的利息成本。二是所争议的相关费用的计算方式与利息计算方式是否类似。三是出借人或其关联方是否提供证据证明实际提供了相关服务，收取服务费、咨询费等费用的主体在无法提供对应服务的情况下，收取费用的行为通常被认定为不具有合理性。四是借款人支付费用的时间与发放借款日的间隔时间。

三、认定“砍头息”后的法律后果

“砍头息”是出借人利用优势地位将利息提前收回，减少了贷款的风险，但损害了借款人的合法利益，使借款人实际上得到的借款少于双方约定的借款数额，影响其资金的正常使用，加重了借款人的负担。为了解决借款实践中出现的这个问题，体现公平原则，防止出借人利用优势地位确定不平等的合同内容，我国法律对于预先扣除利息的行为是禁止的。

《中华人民共和国民法典》第六百七十条、《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第二十六条均对“砍头息”作出了相关的规

定，即出借人提供借款时，如果将利息预先在本金中扣除的，借款人仅按照实际借款数额返还借款并计算利息。《中华人民共和国民法典》第六百八十条关于禁止高利放贷的规定，有利于降低民营企业的融资成本，依法规制民间借贷市场“砍头息”“高息转本”等乱象。在审判实践中，要结合借贷双方合同约定、履行行为和交易习惯，综合判断出借人是否存在“砍头息”行为，更好地维护当事人合法权益，为公民、企业获得融资提供司法保障。

具体到本案，综合借款的转账时间、借款形成经过、利息约定和付款金额等，二审法院认定577.5万元属于案涉借款预先扣除的利息，并在借款本金6600万元中予以扣减，最后认定实际出借本金为6022.5万元，并对一审判决进行了纠正。

编写人：广东省河源市中级人民法院 熊春生 陈旭云

民间借贷中主张利息差额是否构成重复诉讼的认定

——滑某某诉韩某某、董某某民间借贷案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

河南省洛阳市中级人民法院(2023)豫03民终7021号民事判决书

2. 案由：民间借贷纠纷

3. 当事人

原告(上诉人):滑某某

被告(被上诉人):董某某、韩某某

【基本案情】

2013年，董某某向滑某某借款4万元，滑某某将4万元现金交付给董某某。后董某某将上述款项交付给案外人某农林公司，某农林公司向被告董某某支付利息后，被告董某某再将利息支付给滑某某。2015年2月23日，在滑某某催要欠款时，董某某向滑某某出具欠条一张，载明：“董某某欠滑某某4万元。2015年2月23日”。后该款经滑某某多次讨要，被告董某某拒不归还。

2023年1月5日，原告滑某某就其与董某某民间借贷一案诉至法院，要求被告董某某归还欠款本金4万元并支付欠款利息(从借款时起至实际还清之日止，按规定的金融机构的同期同类贷款利率计算);承担因诉讼产生的一切费用(包括但不限于原告及其委托代理人因追还欠款所产生的诉讼费、交通费、误工费等)。

该案经审理，于2023年1月30日作出“51号”民事判决，判决：限被告董某某于本判决生效之日起三日内支付原告滑某某40000元及利息(按照原告起诉时全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率3.65%自2015年2月23日起计算至被告实际偿还之日止)。驳回原告滑某某的其他诉讼请求。

该案判决书送达后，被告董某某不服判决，上诉至二审法院。在二审开庭过程中，被告董某某称：“利息标准是一万元三个月400元。某农业公司把利息转账给我，我现金给滑某某。某农业公司就是按照一万元三个月400元的标准给我的利息，给了多长时间记不清了。我也是按照一万元三个月400元的标准给的滑某某。”原告滑某某称：“利息是按一万元三个月400元，具体时间记不清，大概有一年时间。2013年给，到2014年就拿不到钱了，我们就找她要。”二审法院经审理于2023年4月25日作出判决：驳回上诉，维持原判。

后滑某某不服两级法院作出的生效判决向二审法院申请再审，要求依法改判由被告董某某按约定利息标准(400元/3个月/1万元)向其支付欠款利息(从被告董某某实际收取款项时起计算至还清所有欠款日止);依法判令因董某某违约给其造成的全部损失(包括但不限于诉讼费、保全费、公告费、律师费、执行费等)。二审法院于2023年7月26日作出民事裁定：驳回滑某某的再

审申请。

另查明，被告韩某某与被告董某某于1987年12月26日在洛阳市偃师区民政局登记结婚。2023年9月27日，双方达成离婚调解协议。法院作出民事调解书，确认调解协议：“一、韩某某提出离婚，董某某表示同意。二、其他双方互不追究”。

本次诉讼中，原告滑某某的诉讼请求为：(1)请求法院判令由被告偿还按约定的利息标准(每1万元每3个月给付400元)，以4万元为基数，从2015年2月23日起至被告还清所有欠款日止与“51号”民事判决书中所确定利息的差额部分；(2)请求法院判令因被告违约给原告造成的全部损失(诉讼费)；(3)请求法院判令由被告董某某配偶韩某某与其共同承担前判决“51号”民事判决书及本次诉讼中原告所主张权利的债务连带责任。

【案件焦点】

当事人就民间借贷纠纷中的利息差额再次提起诉讼是否构成重复诉讼、应否得到支持。

【法院裁判要旨】

河南省洛阳市偃师区人民法院经审理认为：关于原告滑某某要求被告董某某支付双方约定的利息与“51号”民事判决书中所确定利息的差额部分是否构成重复诉讼的问题。本诉与前诉的当事人相同，本诉的诉讼标的仍为利息请求权，包含在前诉的借款及利息的请求权之中，尽管本次诉讼原告自称是利息差额部分，但原告首次起诉应当知道与被告约定利息的利率，在第一次起诉中已对利息的请求权作出过处分，本次诉讼再次主张利息请求权，属于对相同诉讼标的的再次诉讼；原告滑某某本次诉讼请求要求利息实际是想否定“51号”民事判决对利息裁判的结果。故，原告滑某某的本次对利息的诉讼请求构成重复诉讼。

关于被告韩某某是否应当承担共同还款责任的问题。本案中，被告董某某向原告滑某某借款4万元的事实尽管发生在被告韩某某与董某某婚姻关系存续

期间，但该笔债务数额较大，借款仅有被告董某某一人，原告滑某某并无证据证明被告董某某的借款用于夫妻共同生活、共同生产经营或基于夫妻双方的共同意思，故，原告滑某某要求被告韩某某承担责任的诉求证据不足，依法不予支持。

河南省洛阳市偃师区人民法院判决如下：

驳回原告滑某某的其他诉讼请求。

滑某某不服一审判决，提出上诉。河南省洛阳市中级人民法院经审理认为：依据滑某某在一审起诉状及其在庭审中的陈述，说明其明知与董某某约定的利息标准，并认可收到董某某按约定标准支付的几次利息，而滑某某在2023年就本案4万元涉及的利息向一审法院提起诉讼，主张利息按金融机构同期同类贷款利率计算，是其对自身权利的处分，其利息诉求权已经过人民法院处理，不应再重复处理，一审法院认为滑某某该项主张属于重复诉讼并无不当。

河南省洛阳市中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

禁止重复起诉即一事不再理原则是对民事诉讼客观规律的正确反映，该原则有利于维护法律尊严和法院权威，有利于保障诉讼效率从而节约有限的司法资源，有利于实现程序的合理性和公正性。认定是否构成重复诉讼应从诉因、当事人、诉讼请求、诉讼标的等方面综合判断。

本案中原告再次起诉理由主要有两点：一是认为原一审判决的利息与实际双方约定的利息存在差额；二是认为案涉债务系夫妻共同债务。原告认为，原一审过程中被告董某某未到庭，加之原告仅有被告书写的借款凭证这一项证据，且借款凭证上并未载明双方约定的利息标准，而借款前期即2013年被告支

付利息的方式为现金，距原一审已过10年有余，因此不能举证证明双方约定利息的标准，但原案件二审期间，被告出庭，并当庭陈述了利息标准，故将二审被告自认的内容作为新的证据，请求判决支持原一审未支持与双方约定利息标准之

间的差额。

《中华人民共和国民事诉讼法》第十三条规定：“民事诉讼应当遵循诚实信用原则。当事人有权在法律规定的范围内处分自己的民事权利和诉讼权利。”本案中，虽然被告原一审未到庭参加诉讼，但结合庭审笔录，审判员对利息部分实际上已作了解，对利息约定的标准、利息给付的方式、借款凭证上为何不显示利息标准等均进行了发问，而原告作为自身权益保障的第一责任人，自然应是最了解案件事实的，但原告依旧将诉讼请求关于利息的部分明确为从借款时起至实际还清之日止按规定的金融机构的同期同类贷款利率计算，实际上属于对自身诉讼权利的处分。同理，原一审判决作出后是否上诉、针对哪些问题上上诉、提出哪些上诉理由、判决生效后是否申请再审、针对哪些问题申请再审、理由如何，均在当事人对自己民事权利和诉讼权利的处分范畴之内。而在原一审中，原告没有进行上诉，应视为对一审判决相关认定的认可，一审法院实际上对本案中争议的利息已经作出裁判。

被告不服原一审判决，认为双方间的借贷关系不成立，提出上诉。二审法院针对上诉请求的有关事实和适用法律进行了审查，因利息标准不是上诉争议的焦点，二审法院自然不必对此问题进行审查，更谈不上错误与否的问题。综上，当事人再次行使诉讼权利有违《中华人民共和国民事诉讼法》规定的诚实信用原则，诉求显然不能成立。

而针对原告的第二项诉求来看，笔者认为，请求判决被告董某某与其配偶韩某某共同承担前判决及本次诉讼原告所主张的权利，不宜从重复起诉的角度驳回原告诉讼请求，理由在于：滑某某起诉被告董某某是基于双方间的借贷关系，而起诉被告韩某某是基于其与董某某之间的婚姻关系。两者是不同的法律关系所产生的争议纠纷，被告董某某和韩某某可以基于不同的法律关系就自身是否需要担责而进行抗辩，诉讼权利互不影响。最高人民法院曾有类似问题的生效案例，^①其中裁判要旨载明：“确认之诉是指一方当事人请求人民法院确认

^①参见(2020)最高法民申2755号民事裁定书，载中国裁判文书网，2025年2月21日访问。

某种民事法律关系存在或者不存在的诉，给付之诉是指一方当事人请求法院判令对方当事人履行一定民事义务的诉。”该案债权人的诉讼请求为“确认生效判决确定的被告向原告连带偿付借款的担保之债系夫妻共同债务”，该诉请系确认案涉债务为夫妻共同债务，没有给付内容，不构成重复诉讼。实际上这样的做法也为司法实践中常见的“赢了官司拿不回钱”的执行难提供了一种新的救济途径。但本案中原告第二项诉讼请求依旧不能得到支持，理由在于：《中华人民共和国民法典》第一千零六十四条坚持“共债共签共同受益”规则，进一步平衡了债权人与未举债一方的合法权益。因此，被告董某某收到原告借款4万元后交付给某农林公司赚取利息，并未用于家庭日常生活或夫妻共同生产经营，原告亦不能举证证明，因此需承担举证不能的不利后果，驳回原告全部诉讼请求。

编写人：河南省洛阳市偃师区人民法院 马玺

借款中介不能实际独立于借贷合同之外的，
其所收取的“融资服务费”应作为还款予以认定

—— 陈某某诉某科贸公司等民间借贷案